

جامعة الجزائر 1

كلية الحقوق سعيد حمدين

محاضرات مقياس تنفيذ العقد

فرع قانون العقود والمسؤولية

السداسي الأول

د/حامي حياة

السنة الجامعية : 2022/2021

مقدمة

إن العقد هو أن تتجه إرادتان أو أكثر إلى إحداث أثر قانوني يتمثل في نشأة الالتزام، إلا أن أثر الالتزام هو وجوب تنفيذه من طرف المدين، و الأصل أن يكون التنفيذ بإرادة المدين و أن يكون عينيا كتسليم البائع للشيء المبيع، وإذا لم يتم التنفيذ بإرادة المدين فللدائن أن يستعين بالسلطة العامة لتنفيذه جبرا إذا كنا بصدد التزام مدني طبقا لنص المادة 160 من القانون المدني على أنه "

المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به....."، و إذا لم يستطع المدين تنفيذ التزامه عينا فللدائن أن يحصل على مبلغ من النقود كتعويض له عن عدم التنفيذ العيني ، وذلك هوالتنفيذ بطريق التعويض أو التنفيذ بمقابل

إن دراسة تنفيذ العقد تقتضي تحديد الأساس القانوني لتنفيذ العقد كمحور أول ثم التنفيذ العيني للالتزام كمحور ثاني.

أولا : الأساس القانوني لتنفيذ العقد :

إن العقد متى نشأ صحيحا يرتب التزامات متبادلة بين المتعاقدين تلك هي آثار العقد، ومن ثم يلتزم المتعاقدين بآثاره، فالإلزامية العقد تقوم على وجوب احترام كل متعاقد على ما التزم به طبقا لنص المادة 106 من القانون المدني على أنه " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون." مما يستلزم تنفيذ مشتملاته ومستلزماته بحسن نية طبقا لنص المادة 1/107 من القانون المدني " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية."

1- مبدأ القوة الملزمة للعقد

إن مبدأ القوة الملزمة للعقد يقصد به أنه بمجرد انعقاد العقد بصفة صحيحة وجب على أطرافه أن ينفذوه كما لو كان قانونا، فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله دون رضا المتعاقد الآخر، فكل ما اتفق المتعاقدان بشأنه من شروط وبنود تأخذ مكانة القانون من حيث القوة، ومن ثم تصبح واجبة التنفيذ ويمنع المساس بها نقضا وتعديلا إذ الإلزامية المقترنة بالعقد تستمد من إرادة المتعاقدين وهذا ما جعل العلاقات العقدية تتميز بالثبات والاستقرار.

ويتقيد بهذه الإلزامية المتعاقدين فأثر العقد نسبي يقتصر على أطرافه دون غيرهم وسيتم توضيح مبدأ القوة الملزمة للعقد من خلال التطرق إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأسس القوة الملزمة للعقد.

أ- قاعدة العقد شريعة المتعاقدين :

إذا نشأ العقد صحيحاً واستكمل القاضي عملية التفسير في حالة الغموض و التكيف تحددت الالتزامات وتولدت للعقد قوته الإلزامية ومن ثم وجب على المتعاقدين و القاضي على حد سوا التقيد به وتنفيذه في جميع ما اشتمل عليه طبقاً لنص المادة 106 و 1/107 من القانون المدني.

لقد ظهرت هذه القاعدة نتيجة سيطرة مبدأ سلطان الإرادة على العقود بالمفهوم الكلاسيكي، غير أنه في ظل المفاهيم الاجتماعية لدور العقد، أصبح لا أحد ينكر على أن القانون هو الذي يكسب العقد قوته الإلزامية وبذلك لا يكسب العقد قوته إلا إذا كان لا يخالف القانون.

تمتاز الرابطة العقدية بالقداسة فلا تلزم المتعاقدين فحسب بل القاضي والمشرع على حد سواء، فيحظر عليهما التدخل والمساس بها .

فلا يستطع القاضي نقض أو تعديل ما قرره الطرفان أما بالنسبة للمشرع فهو ملزم باحترام العقود المبرمة حتى وإن صدر قانون جديد يظل القانون القديم ساري المفعول على تلك العلاقات العقدية ما لم تكن قواعد القانون الجديد متعلقة بالنظام العام بمعنى لا يمكن للمشرع المساس بالاتفاقات العقدية التي تمت على وجه قانوني.

فينحصر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في أمرين :

- **عدم جواز نقض أو تعديل العقد** : يمنع على المتعاقد نقض أو تعديل العقد بإرادته المنفردة ما لم يسمح به القانون على وجه الاستثناء.

فنقض العقد هو تمكين المتعاقد من إنهاء الرابطة العقدية بالإرادة المنفردة دون ترتيب أية مسؤولية عليه طالما لم يتحقق أي تعسف منه، ومنه ينحل العقد بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي ولا يكون إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.

ولا يعد نقض العقد رجوعاً عن العقد الموجب بتشريعات خاصة في إطار حماية المستهلك 119 مكرر 1 من الأمر رقم 10-04 يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض حيث تنص على أنه " يمكن أي شخص اكتتب تعهداً أن يتراجع عنه في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع على العقد" الجريدة الرسمية

2010 العدد 30 الصفحة 15، فيستند حق الرجوع إلى حق المستهلك من الاستفادة من مهلة تفكير إضافية لاحقة للعقد.

كما يتميز نقض العقد عن حق العدول المعمول به في التعاقد بالعربون إذ يترتب عليه سقوط العقد مع فقد العربون أو رده و ضعفه حسب الحالة طبقا لنص المادة 27 مكرر.

ومن ثم فنقض العقد لأسباب قانونية أو اتفاقية فإن مجاله العقود الزمنية أو العقود مؤجلة التنفيذ مجال أعمال نقض العقد فلا يتصور الكلام عن نقض العقد في العقود الفورية غير مؤجلة التنفيذ.

فقد يسمح القانون استثناءا بنقض العقد كما في الوكالة طبقا لنص المادة 587 و 588 من القانون المدني، وهناك عقود يجيز فيها القانون لأحد المتعاقدين دون الآخر أن يستقل بنقضها كعقد الهبة طبقا لنص الماد 211 من قانون الأسرة فيحق للأبوين من الرجوع عن الهبة لولدهما .

أما تعديل العقد يقصد به مراجعة بعض بنود العقد أو إعادة النظر في بعض عناصره ، ويرجع سبب التعديل إلى الظروف الجديدة الخارجة عن العقد وأثرت في تنفيذه وقد تكون ظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية مست التوازن العقدي فاختلفت العدالة العقدية.

ويعتبر تعديل العقد حالة استثنائية و يتم بموجب القانون أو عن طريق القاضي أو ترخيص من القانون أو باتفاق الأطراف معا.

فيتم تعديل العقد بموجب القانون وبالإرادة المنفردة في كثير من الأحيان فيما يتعلق بعلاقات العمل نتيجة التغيرات التي تطرأ على نشاط المؤسسة المستخدمة وكذا العامل، إذ قد يتعين تعديل منصب العامل أو مكانه لأسباب صحية كالمرض والعجز، وقد يكون المستخدم في حاجة إلى تعديل أوقات العمل لاعتبارات اقتصادية مثلا ففي هذا الوضع يكون التعديل بالإرادة المنفردة فإن احتمال التعسف وارد فية ومن ثم يستوجب مراقبة القضاء له .

أما التعديل الاتفاقي فيتمثل في مراجعة بنود العقد بسبب تغير الظروف الاقتصادية التي تنال كثيرا من توازن التزامات المتعاقدين، فلا داعي من اتفاق المتعاقدين على تعديل العقد مالم يتعلق الأمر بحالة لا تتوافر فيها الشروط التي تقتضيها نظرية الحوادث الاستثنائية المادة 2/107 ومثال ذلك انخفاض العملة فيصبح السعر المتفق عليه غير مناسب للوضع الجديد و هذا كلما كان تنفيذ العقد متراجعا أو يتم تنفيذه على فترات متعاقبة، ومثل ذلك نص المادة 2/ 38 من قانون 04-11 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية و المؤرخ في 2011/02/17 حيث تنص عل أنه " كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أو لا و في حالة الايجاب، يجب ذكر كيفية المراجعة ".

2- الزام المتعاقدين بتنفيذ العقد:

غير أنه لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام، فمضمون العلاقة العقدية يتمثل في المسائل الواردة فيها صراحة من حقوق وواجبات محددة وكذلك تلك التي تعد من مستلزمات العلاقة العقدية .

ويجب أن ينفذ الالتزام بحسن نية باعتبار حسن النية من المبادئ الهامة و الأساسية في مجال العقود بدءا من مرحلة التكوين إل مرحلة التنفيذ .

- تنفيذ مشتملات و مستلزمات العقد:

تقضي المادة 1/107 من القانون المدني على وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه فلا يقتصر العقد عل الزام المتعاقد بما ورد فيه بل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام.

فمضمون العقد يتمثل في المسائل الواردة فيه صراحة من حقوق وواجبات محددة وكذا تلك التي لم تحدد إلا أنها من مستلزماته، فإذا المتعاقدان بعض التفاصيل سهوا أو لكونها أمرا مألوفيا بين الناس يكون العقد ناقصا فيتولى القاضي إكماله في حدود القانون والعرف والعدالة.

فعتبر القانون بالنسبة للعقود المسماة المصدر الرئيسي لاستكمال العقد ويكون لدور قواعد القانون في هذا الإطار دورا تكميليا لإرادة المتعاقدين ويجب التفرقة هنا بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة.

فالقواعد الآمرة ملزمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أما القواعد المكملة فلا تلزم المتعاقدين ويحق لهم الاتفاق على مخالفتها.

كما يعد العرف طبقا لنص المادة 2/107 أساسا عقديا يساهم في تحديد نطاق العقد فيعتد به القاضي لاستكمال مضمون العقد، فالعرف سلوك متبع في مسائل معينة بصفة دائمة و متكررة من قبل أفراد المجتمع أو بعض فئاته، اعتقادا منهم أن ذلك السلوك إجباري و إلزامي .

كما تعد العدالة من مستلزمات العقد و يقصد بها الإنصاف و العدل طبقا لما يمليه الضمير و المنطق و طبيعة الأشياء و مصدرها القانون الطبيعي و ليس الوضعي إذ طبقا لنص 2/1 من القانون المدني يجب على القاضي الرجوع إلى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة حالة انعدام نص تشريعي أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو العرف.

- تنفيذ العقد بحسن نية :

يعد مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام من المبادئ الأساسية في مجال العقود بدءا من مرحلة التكوين إلى مرحلة تحديد نطاقها و تفسيرها إلى غاية آخر مرحلة و هي التنفيذ.

ويأخذ مفهومها واسعا فهو يعبر عن الصراحة و القصد السوي والإحساس بالأمانة واستقامة الضمير والنية الصادقة و الصريحة، كما يعبر عن النية التي لا تشوبها الرغبة في الإضرار بالغير و الإساءة إليهم والامتناع عن الغش و التدليس و الخداع و انتفاء التعسف في استعمال الحق، ومن مظاهر حسن النية تكمن فيما يلي :

- الالتزام بالنزاهة :

ويمكن في التحلي بالإخلاص و الامتناع عن الغش و التدليس و مثال ذلك كتمان البائع عن المشتري استحقاق الغير للمبيع، ويتجلى هذا الالتزام في عدة نصوص قانونية من بينها المادة 1/352 من القانون المدني على عدم سقوط حق المشتري في طلب إبطال عقد البيع عند عدم علمه بأوصاف المبيع إذا أثبت غش البائع ، وكذا نص المادة 178 من القانون المدني والذي يقضي بجواز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذه التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه ، وكذا طبقا لنصوص المواد 3/377 و 2/490 و 1/553 من القانون المدني.

- واجب التعاون :

يتمثل واجب التعاون في ضرورة تسهيل تنفيذ العقد و اتخاذ في إطار هذا الهدف كل الاحتياطات التي تملئها المعاملات وحسن النية، فهذا المبدأ يقتضي أن العلاقات العقدية هي علاقات تعاون وليست علاقات خصام وتضارب المصالح، فواجب التعاون عملا بنص المادة 15 من الأمر رقم 07-15 في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-06 في 2006/02/20 يقضي بإلزام المؤمن له بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات الظروف المعروفة لديه والتصريح المسبق بتغير الخطر أو تفاقمه.

وكذا ما تملية المادة 494 من القانون المدني على إلزام المستأجر بإخبار المؤجر فوراً بكل أمر يستدعي تدخله كأن تحتاج العين المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو عيوب أو اغتصاب أو تعرض أو أضرار بها.

3- أثر تدخل القاضي على القوة الملزمة للعقد:

إن القاضي ملزم باحترام قانون العقد كما يحترم القانون إ أن القاضي قد يخرج عن أحكام العقد لحالات حددها القانون و يعمل على تعديله سواء تعلق الأمر في مرحلة انشائه أو تنفيذه قصد مراقبة العمليات التعاقدية و إعادة توازنها ومن مظاهر سلطة القاضي في تعديل العقد خل مرحلة إنشائه التفاوت الفادح بين التزامات طرفي العقد طبقا لنص المادة 90 من القانون المدني حالة الغبن الاستغلالي و المادة 110 حالة الشروط التعسفية إذ يخول لقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها.

ولم يكتف المشرع بمنح القاضي سلطة تعديل العقد أو إعادة التوازن في مرحلة تكوينه بموجب نظرية الغبن الاستغلالي و عقود الإذعان فحسب بل حرص المشرع على حماية أطراف العقد في مرحلة تنفيذه فمنح القاضي في هذه المرحلة سلطة التدخل في العلاقات العقدية القائمة لمواجهة الظروف المتغيرة و التقلبات الاقتصادية التي ينشأ عنها اختلال التوازن العقدي ومن بين هذه الحالات حالة الحوادث الاستثنائية (الظروف الطارئة) المادة 3/107 ق م، و حالة الشرط الجزائي المرهق لأحد المتعاقدين المادة 2/ 184 ق م، وحالة تعديل الأجل الاتفاقي المادة 210 والمادة 2/281 من ق م، و سنقتصر على دراسة الحوادث الاستثنائية طبقا لنص المادة 107/ لتعلقها بآثار العقد أي بتنفيذ مضمون العقد.

- الحوادث الاستثنائية :

الحادث الاستثنائي أو الظروف الطارئة هو حادث عام لاحق على تكوين العقد و غير متوقع الحصول ينجم عن اختلاف في المنافع المتولدة وغير متوقع الحصول، ينجم عن اختلاف في المنافع عن عقد متراخي التنفيذ بحيث أن تنفيذه حسب العقد يرهق أحد الطرفين ويهدده بخسارة فادحة بذلك جاز للقاضي طبقا لنص المادة 3/107 أن يوزع تبعة الحادث بين الطرفين برد الالتزام المرهق للحد المعقول، ويلاحظ الفارق بين الحادث الاستثنائي والقوة القاهرة فمع ان كلاهما غير متوقع الحصول إلا أن الحادث الاستثنائي حادث عام أما الحادث الفجائي فقد يكون فرديا وأن يكون أثر الحادث الاستثنائي هو تعديل العقد أما أثر الحادث الفجائي هو انقضاء الالتزام يجعل تنفيذه مستحيلا فيتحمل الدائن تبعته كاملة، ويلاحظ كذلك الفرق بين الغبن والحوادث الاستثنائية، إذ الغبن يتضمن عدم مساواة في التزامات الطرفين مصاحبة للعقد منذ انعقاده بينما الحادث الاستثنائي هو عدم مساواة طارئة بعد إبرام العقد و خارجة عنه.

- شروط تطبيق نظرية الحوادث الاستثنائية:

يشمل الحادث الاستثنائي كل الأحداث مهما كانت طبيعتها اقتصادية اجتماعية... إلخ، وقد يتمثل الحادث الاستثنائي في قانون أو إجراءات إدارية أو

جبائية جديدة، أما العقود المعنية بهذه النظرية لم تحدد من طرف المشرع بل اكتفى بوجود فاصل زمني بين زمن إبرام العقد وزمن تنفيذه وأن يحصل الحادث خلال هذه الفترة أي يكون العقد زمنيا أو فوريا مؤجل التنفيذ، ويمكن حصر شروط هذه النظري فيما يلي :

- أن يكون العقد متراخي التنفيذ كعقد الإيجار أو فوريا مؤجل التنفيذ.

- أن يكون الحادث استثنائيا عاما نادر الوقوع غير مألوف لا يقع في ظروف عادية كالفيضان والزلازل و الحروب، وتقدير الاستثنائية يكون في الحادث نفسه أو قد ينصب إلى آثاره، فقد يكون الحادث أمرا مألوفا كالتضخم إلا أن آثاره تخرج عما هو معتاد، وإن يكون الحادث عامل غير خاص بالمدين ولا يشترط أن يعم البلاد بل يكفي أن يشمل أثره عددا كبيرا من الناس، كالفلاحين في جهة من الجهات أو التجار بجهة معينة.

- أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين وهذا طبقا لنص المادة 3/107 من ق م فالإرهاق وصف يلحق بالالتزام أحد المتعاقدين بجعل تنفيذه لالتزامه مهددا إياه بخسارة فادحة نتيجة تأثر هذا الالتزام بظرف طرأ بعد إبرام العقد بجعل تنفيذ العقد مرهقا لكن لا يبلغ درجة الاستحالة ، فتتوزع الخسارة بين المدين والدائن و يتحمل المدين شيئا من تبعة الحادث.

فالإرهاق فكرة موضوعية ينظر فيها إلى ظروف العقد وليس ظروف المتعاقد الشخصية ، كالمركز المالي للمدين لتقدير الإرهاق من عدمه، أي ينظر إلى الالتزامات التي رتبها العقد بغض النظر عن ثروة المتعاقدين فمادام معيار تحديد الإرهاق معيارا موضوعيا فيكون المقصود بالخسارة الفادحة كل ما يمس كيان العقد من الناحية الاقتصادية.

- الأثر القانوني لتطبيق نظرية الحوادث الاستثنائية:

إذا توافرت شروط الحادث الاستثنائي فإن القاضي طبقا لنص الماد 3/107 من ق م ملزم بمراجعة العقد ويتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير الخسارة حتى يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويكمن ذلك إما في إنقاص التزام المدين ويكون بإعفاء المدين من تنفيذ قسط مما التزم به كأن يتعهد تاجر بتوريد كميات من السكر

لمصنع و بسبب نشوب حرب منعت استيراده بالكميات اللازمة مما أدى بالتاجر أن يورد المصنع بكميات أقل مما اتفق عليه، فيجوز للقاضي أن ينقص هذه الكميات بالمقدار الذي بمقتضاه يجعل التزام التاجر إلى الحد المعقول.

كما يجوز للقاضي زيادة التزام الدائن و يتحقق بزيادة مقدار العوض الذي يتحصل المدين فطبقا للمثال السابق فعوض أن ينقص من مقدار كمية السكر التي التزم بها المدين يزيد في ثمنه ويبقى المقدار المتفق عليه.

غير أن نص المادة 3/107 باللغة الفرنسية يشير إلى الإنقاص لا الزيادة *reduire* في الالتزام المقابل فالمشرع انصرفت نيته إلى الإنقاص لا غير، إذ لو قصد الزيادة لعبر عنها بصفة صريحة كما ورد في نص 3/561 من ق م .

ثانيا: التنفيذ العيني للالتزام

لقد وضع المشرع فصلا كاملا للتنفيذ العيني من المادة 164 إلى المادة 175 من ق م ، مع التمييز بين التنفيذ العيني الاختياري و التنفيذ العيني الجبري ، إذ تناول التنفيذ العيني الجبري في آثار الالتزام طبقا لأحكام القانون المدني و أحكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية ، بينما تناول التنفيذ العيني الاختياري في الباب الخامس من الكتاب الثاني من القانون المدني تحت عنوان انقضاء الالتزام ولم يسميه المشرع بالتنفيذ العيني الاختياري بل سماه الوفا بالالتزام .

فالأصل أن يكون تنفيذ الالتزام الذي يترتب عليه العقد بإرادة المدين وأن يكون عينيا أي بتقديم المدين عين ما التزم بأدائه كتسليم البائع للشيء المبيع .

وقد نصت المادة 164 من ق م عل أنه يجبر المدين بعد إعداره طبقا لنص كل من المادة 180 و 181 من ق م على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا بمعنى أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل طالما كان ذلك ممكنا ، والتنفيذ العيني يقصد به أن يوفي المدين بعين ما التزم به في مواجهة الدائن ، وللدائن الحق في مطالبة المدين به فإن لم يفعل كان للدائن حق إجبار المدين عليه طالما كان في إمكان المدين القيام به ، أما إذا استحال على المدين التنفيذ العيني لا يكون أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض.

ويجب في هذا الإطار عدم الخلط بين التنفيذ العيني و التنفيذ بمقابل أو التنفيذ عن طريق التعويض ، فالتنفيذ العيني هو الأثر الحقيقي للالتزام وهو الحق المخول للدائن لكي يجبر المدين على تنفيذ عين ما التزم به وما هو إلا تطبيق لمبدأ القوة الملزمة للعقد فهو ملزم على الطرفين و القاضي في آن واحد.

أما التنفيذ بمقابل يقوم عند استحالة التنفيذ العيني للالتزام بخطأ المدين، أو إذا كان هذا التنفيذ يستلزم تدخل المدين الشخصي وامتنع عن التنفيذ رغم التهديد المالي في التغلب عن تعنته ، ويقوم كلك حالة إذا طالب الدائن التنفيذ العيني إلا أن هذا التنفيذ كان مرهقا عل لمدين وكان عدم القيام به لا يعود بضرر جسيم عل الدائن وهذا طبقا لنص المادة 176 من ق م .

ف طالما أن التنفيذ العيني ممكنا فإن المدين يجبر على هذا التنفيذ و لا يلجأ القاضي إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني .

1- شروط التنفيذ العيني للالتزام :

الأصل الوفاء الاختياري للالتزام أما الاحتياط هو التنفيذ الجبري على المدين ، ولكي يتمكن الدائن من المطالبة القضائية لتنفيذ الالتزام المتفق عليه تنفيذا عينيا جبريا لابد من توافر شروط محددة.

أ- امكانية التنفيذ العيني:

يحق للدائن أن يطلب التنفيذ العيني طالما كان ذلك ممكنا فإذا أصبح مستحيلا بسبب أجنبي لتعلقه بمحل الالتزام كهلاك الشيء أو أصبح العمل الذي التزم به المدين مستحيلا فهنا ينقضي الالتزام طبقا لنص المادة 307 من ق م، أما إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين لم يبق أمام الدائن سوى المطالبة بالتعويض .

ويعتبر تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن إذا كان يقتضي تدخل المدين على أساس شخصية المدين محل اعتبار، ويرفض هذا الأخير القيام بذلك فامتناع الرسام عن

الرسم يترتب عليه استحالة التنفيذ إذ لا يتصور استخدام القوة لجبر الرسام على الرسم فلا مجال للدائن في هذا الوضع إلا المطالبة بالتعويض .

ويتصور استحالة تنفيذ التنفيذ العيني في جميع أنواع الالتزام ماعدا الالتزام بدفع النقود ، إذ لا يمكن تصور استحالة تنفيذه في حالة إعسار المدين ولا يمكن تصور لجوء الدائن إلى القضاء لطلب التعويض .

ب- عدم إرهاب المدين :

قد لا يكون التنفيذ العيني مستحيلا لكن فيه إرهاب للمدين بحيث يترتب عل إجباره عليه ضرر فادح لا يتناسب مع ما يلحق الدائن جراء عدم التنفيذ فهنا يجب على القاضي الموازنة بين عدم إرهاب المدين عند إرغامه على التنفيذ العيني و بين الأضرار التي تلحق الدائن عند عدم إرهاب المدين عند إرغامه على التنفيذ ، وبالتالي فإذا أمكن تفادي إرهاب المدين ولو بضرر يسير للدائن جاز العدول عن التنفيذ العيني إل التنفيذ بمقابل، أما إذا حدث العكس فيجب الرجوع إلى الأصل وهو وجوب التنفيذ العيني للالتزام وهذا ماتبناه المشرع الجزائري راجع المواد 785 و 786 و 788 و 790 من القانون المدني .

ج- عدم مساس التنفيذ العيني بشخصية المدين :

إذا كان في طلب التنفيذ العيني مساس بحرية المدين فلا مناص أن يتحول إل طلب التعويض فلا يمكن إجبار الطبيب على تنفيذ التزامه جبرا لأن ذلك يعد مساسا بشخصه و لا يبقى أمام الدائن سوى اللجوء الوسائل غير المباشرة لحث المدين على التنفيذ و يكون ذلك بالإكراه المالي عن طريق الغرامة التهديدية فإن امتثل المدين في هذه الحالة فإن التنفيذ العيني قد تحقق وإن امتنع فلا مناص حينئذ من المطالبة بالتعويض .

د – الإعذار

لا يمكن إلزام المدين بالتنفيذ أو التعويض إلا إذا أظهر الدائن رغبته في حث المدين عل التنفيذ و يكون عن طريق توجيه إعذار للمدين طبقا لنص المادة 164 من ق م والتي تحيل إل المادة 180 – 181 من ق م و الهدف من هذا الإجراء هو تبيان

الإرادة الجدية للدائن في مطالبته ويجب أن تتحقق ثمة شروط في الإعذار حتى يحق للدائن التمسك به :

- **التأخير في تنفيذ الالتزام** وهو التأخير الفعلي دون مبرر ويكون بفعل المدين باستبعاد القوة القاهرة والسبب الأجنبي أو فعل الغير.

- **أن يكون الحق المتمسك به مشروعاً ويحميه القانون** فلا مجال للإعذار للمطالبة بدين سقط بالتقادم أو نشأ عن طريق القمار.

- **أن يكون الحق معين المقدار و مستحق الأداء** فإذا كان معلقاً على شرط واقف و لم يتحقق هذا الشرط فلا يحق للدائن توجيه الإعذار إلى مدينه لعدم حلول أجل الوفاء بسبب عدم تحقق الشرط.

- **أن يتم الإعذار طبقاً لمقتضيات المادة 180 من ق م على** أن يكون الإعذار بإنذار المدين عن طريق محضر قضائي ، و يجوز أن يتم عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول كما يجوز أن يتم بمجرد حلول الأجل إذا تم الاتفاق على أن يكون المدين معذراً بحلول .

2- النطاق الموضوعي لحق الدائن في التنفيذ العيني :

إن النطاق الموضوعي لتنفيذ الالتزام يشمل جميع ما تضمنه العقد من حقوق و التزامات أي ينحصر في محل الالتزام المراد تنفيذه عينياً فقد يكون محل الالتزام المطالبة به شيء من الأشياء المادية ، أو عيناً من الأعيان و قد يكون عملاً من الأعمال أو مبلغاً من النقود أو شيئاً معنوياً .

أ- الأشياء أو الأعيان المادية كمحل التنفيذ العيني :

إن نطاق التنفيذ العيني على الأشياء قد يشمل محله الزام المدين بمنح عين من الأعيان أو شيء مادي آخر، وقد يكون منقول أو عقار.

- **التنفيذ العيني للالتزام بمنح شيء منقول**

وهنا قد يكون منقول مادي معين بالذات أو بالنوع وهذا ما يتم توضيحه كما يلي :

-تنفيذ الالتزام الذي يرد على منقول معين بالذات :

ويكون تنفيذ هذا النوع من الالتزام بقوة القانون طبقا لنص المادة 165 من ق م فالالتزام بنقل الملكية يقع بقوة القانون ، فيتم التنفيذ العيني بمجرد نشأة الالتزام ومن ثمة لا يمكن تصور امكانية إجبار المدين على القيام بالتنفيذ.

غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات التابعة للالتزام بنقل الملكية كالاتزام بالتسليم فإنه يحق للدائن تحريك اجراءات التنفيذ العيني وإلزام المدين بالتسليم المادة 167 من ق م .

- تنفيذ الالتزام الذي يرد على منقول معين بالنوع

وهي المنقولات أو الأشياء التي تقوم بعضها مقام الآخر في التنفيذ وهي تقدر بالوزن أو الكيل أو العدد أو المقاس... إلخ ، وتنتقل الملكية فيها عن طريق قيام المدين بعمل ايجابي وهو فرز المنقول، وتنتقل الملكية فيه لحظة الفرز مباشرة إلى الدائن وليس من لحظة التسليم وإن امتنع المدين على ذلك يحق للدائن أن يجبره ، وإذا لم يمتلك المدين منقولات مثلية من نفس النوع فإنه يحق للدائن الحصول على مثيلاتها في السوق على ذمة المدين بعد إذن القاضي .

- تنفيذ الالتزام الذي يرد على عقار أو حق عيني

تعتبر العقود الواردة على العقار من العقود الرسمية طبقا لنص المادة 324 مكرر 1 من ق م و لا تنتقل ملكيتها إلا بالتباع إجراءات الشهر طبقا لنص المادة 793 م ق م ففي هذا الوضع الموثق هو الذي يقوم بإجراءات الشهر وليس المدين وإلا تعرض لعقوبات تأديبية .

ب - الأعمال كمحل للتنفيذ العيني

إن الأداء الذي يلزم به المدين قد يكون عمل ايجابي مثل الالتزام بقيام بعمل أو أن يكون عمل سلبي مثل الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل .

- الالتزام بالقيام بعمل كمحل للتنفيذ العيني:

إن محل هذا الالتزام قد يكون عمل مادي مثل الالتزام بالبناء وقد يكون عمل قانوني مثل قيام الوكيل بتصرف نيابة عن الموكل ، غير أنه يمكن حصر هذه الأعمال في الالتزام بتحقيق نتيجة أو الالتزام ببذل عناية ، ففي الوضع الأول لا يكون المدين قد نفذ التزامه إلا إذا تحققت النتيجة المطلوبة منه .

أما في الوضع الثاني فإن المدين ملزم ببذل عناية الرجل العادي طبقا لنص المادة 172 من ق م .

- الامتناع عن عمل كمحل للتنفيذ العيني

وهو الالتزام الذي يكون محله امتناع عن عمل يمكن للمدين القيام به لو التزمه به ، فالتنفيذ يتحقق في الامتناع عن القيام بالعمل ، و عند القيام بالعمل فإنه يكون قد خالف مضمون الالتزام التعاقدي ، الأمر الذي يفتح المجال للدائن للمطالبة بإجباره على الكف عن إخلاله بالتزامه بالامتناع عن العمل ، أو الحصول على رخصة من القاضي لإزالة ما وقع مخالفا للالتزام على المدين طبقا لنص المادة 173 من ق م ، ومن أمثلة الالتزام بالامتناع المادة 361 من ق م و المادة 492 من ق م .

ج – النقود كمحل للتنفيذ العيني

تعتبر النقود من المثليات المعينة بالنوع أي يجب تحديد محل الالتزام النقدي حتى يكون المدين مدركا بما هو مطالب به سواء كان محل العقد الأصلي هو مبلغ النقود مثلما هو الحال في عقد القرض ، أو أن مبلغ النقود هو هو التزام من التزامات المدين مثل الالتزام بدفع الثمن في عقد البيع ، ولا يتم تنفيذ الالتزام بدفع النقود عن طريق فرزها و إنما عن طريق قبضها من الدائن وهي تكون دائما قابلة للتنفيذ العيني و لا تتعرض للهلاك ومن ثمة لا يجوز التنفيذ عن طريق التعويض إذا كان الالتزام يتضمن دفع مبلغا من النقود، بل يجوز في حالة التأخير في الوفاء بالالتزام طبقا لنص

المادة 186 من ق م و لا تتأثر قيمة النقود بتغير الظروف طبقا لنص المادة 95 من ق م .

د- التنفيذ العيني للالتزام المعنوي

الالتزام المعنوي هو الالتزام الوارد على شيء معنوي ويحق للدائن الحصول على المقابل الناتج عن عمل فكري كحق المخترع في اختراعاته وهو ما يعبر عنه بالحقوق الذهنية أو الأدبية.

المحور الثالث : وسائل الضغط لإلزام المدين على تنفيذ الالتزام :

لقد تضمن القانون المدني على مجموعة من الوسائل التي تسمح للدائن الضغط على المدين حتى ينفذ التزامه طبقا للأحكام الواردة في العقد، وتتنوع هذه الوسائل من وسائل قانونية واتفاقية وقضائية .

أولا : الوسائل القانونية للضغط المدين لتنفيذ التزامه :

تتصدر هذه الوسائل في الدفع بعدم التنفيذ وفي الحق في الحبس

1- الدفع بعدم التنفيذ : (الامتناع المشروع عن الوفاء)

يعرف الدفع بعدم التنفيذ بأنه حق الدائن المتعاقد في العقد الملزم للجانبين في الامتناع عن تنفيذ في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقيم المتعاقد الثاني بتنفيذ الالتزام المقابل له وهذا طبقا لنص المادة 123 من ق م ، و ينتسب مبدأ الدفع بعدم التنفيذ إلى مبدأ أعم هو الحق في الحبس الذي تناوله المشرع في نص المادة 200 من ق م ففي الحق في الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له فيكون هذا الارتباط أساسا للحق في الحبس فمن حاز شيئا مملوكا للغير كالمودع لديه والمستعير والمرتهن رهنا حيازيا و أنفق على هذا الشيء مصروفات ضرورية أو نافعة كان له أن يستردها .

فالحائز مدين للمالك برد الشيء و دائن له باسترداد المصروفات ، لذلك يجوز للحائز أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يتقاضى من المالك حقه و هذا هو الحق في الحبس ، وهو بهذا المفهوم يتسع ليدخل في نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد فالبائع مدين

بتسليم المبيع ودائن بقبض الثمن فمن حقه حبس العين حتى يستوفي الثمن ، وهذا تطبيق للحق في الحبس في العقود الملزمة للجانبين و هو في نفس الوقت تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد ، و بذلك يكون الدفع بعدم التنفيذ فرعا عن الحق في الحبس فحيث يطبق الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين كان هذا هو الدفع بعدم التنفيذ فإذا خرج عن هذا النطاق عاد حقا في الحبس لا دفعا بعدم التنفيذ ، فحبس المصروفات الضرورية أو النافعة في عقود العارية أو الوديعة مثلا لا يكون دفعا بعدم التنفيذ بل حقا في الحبس فالدفع بعدم التنفيذ محصور في العقود الملزمة للجانبين .

- شروط الدفع بعدم التنفيذ:

- أن نكون بصدد عقد ملزم للجانبين طبقا لنص المادة 123 من ق م .
- أن يكون حق الدائن المتمسك بالدفع مستحق الأداء حالا

- حق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ :

- عدم ضرورة الاعذار فلا يحتاج المتمسك بهذا الدفع إلى اعذار المتعاقد الآخر.

- ترك أمر الدفع إلى تقدير المتمسك فلا يحتاج لتقدير القاضي إلا أنه قد يرد أمر الدفع بعدم التنفيذ إلى القضاء إذا تمسك أحد الطرفين به فيستطيع الطرف الآخر أن يرفع الأمر إلى القضاء قصد تقدير موقف من تمسك به فقد يقره القضاء وقد يقره.

- آثار الدفع بعدم التنفيذ

ويمكن حصر هذه الآثار بين المتعاقدين وتجاه الغير

- فيما بين المتعاقدين :

1- وقف التنفيذ في الالتزام بنقل الملكية : إذا كان الالتزام الموقوف هو التزام بنقل حق عيني كاللزام البائع بنقل حق عيني كان على البائع أن يعمل على مساعدة الموثق لتمكينه من شهر العقد إذا تعلق بعقار مثلا .

2- إذا كان الالتزام الموقوف هو التزام بعمل كاللزام المقاول بالبناء كان لهذا الأخير أن يتوقف عن أعمال البناء لغاية تنفيذ رب العمل ما التزم به .

3- إذا كان الالتزام الموقوف هو التزام بتسليم عين حبس المتمسك بالدفع العين حتى يستوفي حقه من المتعاقد الآخر فالبائع لا يسلم العين حتى يستوفي الثمن .

- بالنسبة للغير :

يسري الدفع بعدم التنفيذ في حق الغير إذا كان هذا الغير قد اكتسب حقه بعد ثبوت الحق في التمسك بالدفع ، مثال ذلك إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن فمن حق البائع أن يتمسك بالدفع و يحبس العين المبيعة فكل من اكتسب حقا من المشتري على العين المبيعة بعد التمسك بالدفع يسري في حقه الدفع فإذا باع المشتري العين إلى مشتري ثاني جاز للبائع أن يبقى حابسا للعين في مواجهة المشتري الثاني ، وتبرير ذلك بأن المشتري لم ينقل إلى خلفه حقوق أكثر مما له وقد كانت حقوقه خاضعة لهذا الحق ، ولا يستطيع المشتري أن ينقل حقا لا يملكه.

2- الحق في الحبس :

يرجع أساس فكرة الحق في الحبس إلى فكرة العدالة و حسن النية التي يجب أن تسود العلاقات و التي تقتضي أن يسلم المدين ما في ذمته إلى غيره قبل أن يقبض ما له من حقوق في ذمة الغير.

و قد نظمه المشرع في المواد 200 إلى 201 من ق م و يقصد به مسك الشيء واحتجازه طبقا لنص المادة 200 من ق م على أنه كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالالتزام ترتب عليه و له علاقة سببية وارتباط بالالتزام المدين فهو حق مقرر لكل شخص يكون دائنا و مدينا في آن واحد و يجوز له الاحتفاظ بما لديه من مال يخص مدينه ما دام أن هذا الدائن لا يؤدي ما يجب عليه .

فحق الحبس يفترض وجود التزامين كل منهما مترتب عن الآخر و مرتبط به سواء كان مصدر هذا العمل القانوني العقد أو الواقعة القانونية كالإثراء بدون سبب ، ففي البيع مثلا فإن التزام كل متعاقد مرتبط بالتزام المتعاقد الآخر وبذلك فالبايع والمشتري كل منهما له أن يحبس ما لتزم بأدائه حتى يفي المتعاقد الآخر بالتزامه .

وعليه يعد الحق في الحبس طريق ممهد للتنفيذ لأنه يلزم المدين بالوفاء بالتزامه على الغالب إذا لم يقم المدين بهذا الوفاء وجب على الحابس الحصول على حكم بحقه و لا يحق له التنفيذ على المال المحبوس أو غيره دون حكم .

الطبيعة القانونية لحق الحبس :

اختلف الفقه و القانون في تحدي الطبيعة القانونية لحق الحبس فذهب الفقه الفرنسي على أنه حق عيني غير تام لأنه لا يمنح حق الأفضلية و أنه حق عيني لأنه قابل للاحتجاج به على الكافة .

إلا أن الرأي الراجح على أن الحق في الحبس هو دفعا من الدفوعات يفقد المقومات الأساسية للحقوق العينية و لا يشتمل لا على حق التقدم أو التتبع و لا يخضع لإجراءات الشهر، ومنه يعد الحق في الحبس كضمان خاص أعطاه المشرع لكل دائن ومدين في نفس الوقت لحبس المال حتى يستوفي حقه .

حقوق الحابس: للحابس حقوق تترتب على حبسه للعين و تتمثل

- **الامتناع عن تسليم العين:** يتمتع الحابس عن تنفيذ التزامه حتى يستوفي حقه كاملا من أصل و فوائد و مصروفات و الحق في الحبس لا يقبل التجزئة ، فلا يجبر الحابس حالة الوفاء الجزئي تسليم جزء من الشيء المحبوس بل له أن الامتناع عن تسليم جملة الشيء حتى يستوفي حقه كاملا غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة يحد منها مبدأ التعسف في استعمال الحق بمعنى يجوز للقاضي إلزام الحابس بتسليم الشيء إذا كان ما لم ينفذ من التزام المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام .

و لا يمنح حق الحبس امتياز للحابس على العين المحبوسة طبقا لنص المادة 201 من ق م و من تم إذا نفذ الدائن على العين المحبوسة فإنه ينفذ عليها كدائن عادي و ليس كدائن ممتاز .

- **واجبات الحابس :** بالرجوع إلى نص المادة 2/201 من ق م يستخلص أن للحابس واجبات تتمثل في

المحافظة على العين المحبوسة : يلتزم الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس و وفقا لأحكام رهن الحيازة طبقا لنص المادة 955 من ق م .

فالحابس ملزم ببذل عناية في المحافظة وهو معيار موضوعي ينظر فيه إلى عناية الرجل العادي ، فإذا قصر اعتبر مخلا وتحققت مسؤوليته التقصيرية لخطئه.

ويتفرع عن هذا الالتزام واجب آخر طبقا لنص المادة 3/201 من ق م وهو حالة ما إذا كان الشيء المحبوس سريع الهلاك أو التلف يتعين عل الحابس اتخاذ إجراءات بيعه بعد استئذان القاضي دون أن يعتبر ذلك نزولا عن حقه في الحبس ، بل ينتقل حقه إلى الثمن وفقا لنظرية الحلول العيني و يعين القاضي في هذه الحالة الجهة التي يودع فيها الثمن فقد يقضي بإيداعه عند شخص ثالث أو في خزانة المحكمة أو لدى الحابس نفسه طبقا لنص المادة 2/971 من ق م .

تقديم حسابي عن الغلة : إذا كانت العين المحبوسة محل انتاج ثمار أو غلة فإن ما تنتجه يكون من حق مالکها و ليس الحابس الحائز، فعلى الحابس إذا استوفى حقه أن يرد العين المحبوسة و غلتها و تقديم حساب عن هذه الغلة لمالکها طبقا لنص المادة 972 من ق م .

- **رد العين المحبوسة :**

يلتزم الحابس برد العين المحبوسة للمالك عند انقضاء الحق في الحبس ولا يعد الحق في الحبس مصدرا لرد العين المحبوسة ولكن إذا انقضى الحبس زال المانع الذي كان يحول دون رد العين وفقا للعلاقة القانونية التي كانت تربط الدائن و الحابس باعتبار الحبس واقعة مادية .

- ثانيا : الوسيلة الاتفاقية للضغط على المدين لتنفيذ الالتزام : وتتمثل هذه الوسيلة في الشرط الجزائي

مفهوم الشرط الجزائي :

يعرف الشرط الجزائي بأنه اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه و يشترط لاعتباره شرطا جزائيا أن يتم قبل الإخلال بالالتزام ، أما لو تم بعد ذلك فإنه يعتبر اتفاقا على تعويض مستحق بالفعل فالشرط الجزائي تقدير اتفاقي للتعويض سواء عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه و يقدر مقدما طبقا لنص المادة 18 من ق م .

- الغاية من الشرط الجزائي :

يهدف المتعاقدان من الشرط الجزائي إلى تسوية عدة أو ضاع قانونية يمكن حصرها فيما يلي :

1 - تجنب الإجراءات و المصاريف القضائية .

2- تجنب مشاكل تقدير التعويض من طرف القاضي المادة 182 من ق م والذي قد ينتهي بعدم قبوله من أحد الأطراف أو كليهما مما يفتح باب الطعن في أحكام القضاء ومن ثمة إطالة النزاع .

3- وسيلة للتخفيف من مسؤولية المدين إذا كان التعويض المتفق عليه أقل من قيمة الضرر الحاصل إلا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما المادة 185 من ق م .

4 - وسيلة للضغط على المدين خاصة إذا كانت قيمة التعويض المتفق عليه أكبر من الضرر الفعلي الحاصل .

5- إعفاء الدائن من إثبات الضرر عكس ما تملّيه القواعد العامة ففي الشرط الجزائي يفترض الضرر بمجرد تأخر المدين في التنفيذ أو عدمه .

- خصائص الشرط الجزائي :

يتميز الشرط الجزائي بجملة خصائص :

- 1- إنه التزام تابع لالتزام أصلي وهو ما التزم به المدين .
- 2- إنه التزام احتياطي فهو تعويض فهو طريق احتياطي عند عدم التنفيذ العيني فالأصل التنفيذ العيني .
- 3- إنه تقدير جزافي في التعويض لأنه تقدير مسبق قبل حصول الضرر .

- حالات استبعاد إعمال الشرط الجزائي:

لقد تدخل المشرع للحد من إعمال الشرط الجزائي في حالات محددة إذ نص القانون على تحديد مقدار التعويض المتفق عليه عند إخلال المتعاقد بالتزامه فإنه لا يجوز أن يتجاوز القيد المحدد قانونا كالقانون رقم 74-15 المؤرخ في 30/01/1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث السيارات ، فليس للمصاب بحادث مرور أن يتفق مع مرتكب الفعل على مبلغ التعويض لأن القانون السالف الذكر قد حدد طرق التعويض ، كما منع المشرع إعمال الشرط الجزائي طبقا لنص المادة 78 من الأمر 75-31 المؤرخ في 29/04/1975 المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص إذ منع رب العمل من استعمال الشرط الجزائي والذي يأخذ شكل غرامة تستقطع من راتب العمل والهدف من هذا المنع هو ضمان الحد الأدنى من الأجر فاقتطاع مبلغ الشرط الجزائي قد يؤثر عليه و يجعله لا يصل إلى الحد الذي يضمنه القانون .

شروط استحقاق الشرط الجزائي :

لاستحقاق التعويض الجزائي لابد من قيام مسؤولية مدنية عقدية تتلخص عناصرها في خطأ من جانب المدين ، و ضرر من جانب الدائن فطبقا لنص المادة 1/184 من ق م لا يستحق الدائن التعويض الاتفاقي إلا عند حدوث الضرر وعلى

المدين أن يثبت عدم تحقق الضرر للدائن ، ولا بد من توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا انتفت هذه العلاقة بإثبات السبب الأجنبي أو أن الضرر كان غير مباشر أو غير متوقع فلا تتحقق المسؤولية ومن ثمة لا تعويض إلا أنه استثناءا يجوز الاتفاق عل تحميل المدين تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة طبقا لنص المادة 1/178 من ق م .

سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي :

يحق للقاضي التدخل لتعديله عن طريق التخفيض طبقا لنص المادة 2/184 من ق م سواء كان الشرط مفرطا أو إذا قام المدين بالتنفيذ الجزئي لالتزامه ويجوز للقاضي استثناءا العمل على الزيادة في الشرط الجزائي وسيتم توضيح كل حالة على حدى :

- تخفيض الشرط الجزائي :

- حالة التقدير المفرط : لقد نص المشرع في نص المادة 2/184 على أنه يجوز للقاضي أن يخفض التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغ فيه أي عدم التناسب الكبير بين قيمة التعويض والضرر الحاصل مما يؤدي إلى إرهاب المدين فهنا يجوز للقاضي رفع الإرهاب عن طريق تخفيض قيمة الشرط الجزائي.

- حالة التنفيذ الجزئي للالتزام طبقا لنص المادة 2/184 يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه خاصة إذا كان هذا التنفيذ الجزئي مقبولا من طرف الدائن و محققا لمصلحته .

و لا يحقق للقاضي تخفيض الشرط الجزائي إلا إذا تحققت ظروف تكمن فيما يلي :

- أن يكون التنفيذ الجزئي ممكنا معناه أن يكون الالتزام بطبيعته قابلا للتجزئة .

- أن يحقق التنفيذ الجزئي مصلحة للدائن معناه أن الجزء الذي تم تنفيذه مهما وليس تافها بالنسبة للدائن .

- أن يقبل الدائن التنفيذ الجزئي فاشتراط قبول الدائن التنفيذ الجزئي لإمكانية تخفيض الشرط الجزائي يعتبر من القواعد العامة المتعلقة بالوفاء كسبب لانقضاء الالتزام المادة 1/277 من ق م .

- أن لا يتم التنفيذ الجزئي في التزام مستقل فإذا وضع الشرط الجزائي ليشمل عدة التزامات و قام المدين بتنفيذ إحداها فلا يعد ذلك تنفيذا جزئيا يقتضي تخفيض التعويض المتفق عليه .

الزيادة في قيمة الشرط الجزائي فإذا كان القانون قد خول للقاضي سلطة تخفيض الشرط الجزائي حالتي التقدير المفرط أو التنفيذ الجزئي للالتزام ، فإن الأمر ليس كذلك حالة الزيادة إذ يمنع على القاضي أصلا الزيادة في الشرط الجزائي إلا استثناءا طبقا لنص المادة 185 متى أثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما .

ثالثا : الوسيلة القضائية للضغط على المدين لتنفيذ التزامه

لقد سمح القانون في الالتزامات بعمل والتي فيها شخصية المدين محل اعتبار للقاضي بإصدار حكم يقضي بإلزام المدين بأداء غرامة مالية عن كل تأخير لم يقم فيه بتنفيذ ما التزم به وتتمثل هذه الوسيلة في الغرامة التهديدية.

مفهوم الغرامة التهديدية : (التهديد المالي)

استقر الفقه على أن الغرامة التهديدية عبارة عن وسيلة غير مباشرة لحمل المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا عندما لا يكون ذلك التنفيذ ممكنا إلا إذا نفذ المدين شخصا ، وتقوم هذه الغرامة بموجب حكم يصدره القاضي ضد المدين بوجوب التنفيذ العيني في مدة محددة بفرض غرامة مالية عليه على سبيل التهديد عن كل وحدة زمنية قد تكون يوم أو أسبوع إلخ يتأخر فيها عن التنفيذ ، حتى يقدم على تنفيذ التزامه .

فالغرامة التهديدية عبارة عن مبلغ مالي يقدره القاضي عن كل تأخير في التنفيذ نمها القانون بموجب المادة 1/174 من ق م ، فالغرامة التهديدية وسيلة لحمل المدين على التنفيذ العيني إذا كنا بصدد التزام بعمل و المطلوب أن يؤديه المدين نفسه

كامتناع طبيب معين عن أداء العمل المتعاقد عليه كان على القاضي الحكم بإلزامه بهذا العمل وإلزامه في نفس الوقت بدفع أداء مالي عن كل فترة تأخير عن التنفيذ ، فالغرامة ليست تعويض للضرر و إنما حمل المدين تحت وطأة التهديد المالي بأن ينفذ ما التزم به .

- شروط الحكم بالغرامة التهديدية :

1- أن يكون التنفيذ العيني مازال ممكنا غير مستحيل بسبب أجنبي لا يد للمدين ، أما إذا كانت الاستحالة بفعل المدين فلا يحكم هنا بالغرامة التهديدية و إنما بالتعويض .

2- أن يكون تنفيذ الالتزام عينا إلا من طرف المدين فقط أي لا بد أن يصدر من المدين نفسه شخصا أما إذا كان التنفيذ العيني ممكنا دون تدخل المدين نفسه وكان موضوع الالتزام عملا يمكن تنفيذه بواسطة الغير جاز الحكم في هذه الحالة بتنفيذه بواسطة الغير على نفقة المدين دون الحكم بالغرامة التهديدية طبقا لنص كل من المادة 169 و 170 من ق م .

- خصائص الغرامة التهديدية : إن الحكم بالغرامة التهديدية ليس تعويض فلا تقاس بمقدار الضرر وبذلك تتميز بجملة خصائص

1- الحكم بالغرامة التهديدية حكم تهديدي الغرض منه الضغط على المدين يراعى في تقديره قدرة المدين دون جسامته الضرر ، ومن ثمة يجوز للقاضي إعادة النظر في حكم الغرامة إذا تبين أنها لم تكن كافية لحمل المدين على التنفيذ المادة 2/174 من ق م .

2- أنه حكم غير محدد المقدار إذ تتحدد الغرامة بفترات التأخير عن التنفيذ عن كل يوم أو شهر لذلك لا يمكن معرفة مجموع الغرامة يوم صدور الحكم بها إذ قد يزداد مع مرور كل يوم دون تنفيذ وبذلك لا يمكن اعتبارها دينا محققا في ذمة المدين و لا يمكن تنفيذها إلا بعد أن يقوم القاضي بالتصفية النهائية .

3- الحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت فيعد الحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يكون قابلا للتنفيذ إلا برجوع الدائن

أمام الجهة القضائية المختصة من جديد لإعادة النر في مقدار الغرامة و تصفيته ، و يحكم على أساس التأخر في التنفيذ بتعويض إجمالي و هو الواجب التنفيذ.

ويجوز للقاضي المختص تعديل مقدار الغرامة التهديدية كلما دعت الضرورة ، فبناء عل طلب الدائن يجوز للقاضي أن يعيد النظر في قيمتها أو تحويلها إلى تعويض إجمالي حسب الضرر الناجم للدائن من جراء التأخر الحاصل في التنفيذ العيني ومدى تعنت المدين طبقا لنص المادة 175 من ق م .

- آثار الحكم بالغرامة التهديدية :

تتحدد هذه الآثار من خلال موقف المدين الذي سيتخذه تجاه التنفيذ فإما الانصياع و الامتثال أو عدم الرضوخ للتهديد المالي ، وعليه فإن المدين سنتهي باتخاذ أحد الموقفين الأول يتمثل في التوقف عن العناد والامتثال للتنفيذ خشية تراكم الغرامة التهديدية والثاني يتمثل في التمسك بالامتناع و الإصرار عل عدم القيام بتنفيذ التزامه رغم التهديد المالي .

وفي الحالتين يكون موقف المدين بصفة نهائية إيجابا أو سلبا ومن خلالها يكون التهديد المالي قد استنفذ الهدف الذي وجد من أجله لذا الاستبقاء على الغرامة التهديدية لم يعد مجديا و أصبح من اللازم النظر في مصيرها بغرض تحويلها إلى تعويض نهائي .

1- سلطة القاضي في تعديل الغرامة التهديدية

إذا حكم عل المدين بغرامة تهديدية فإما أن ينفذ الالتزام فهنا يعمل القاضي على خفض قيمة الغرامة المحكوم بها عليه بما يتساوى و الضرر الحاصل للدائن، أما إذا أصر عل عدم التنفيذ فيعمل القاضي على رفعها طبقا لنص المادة 174 / 2 من ق م ، غير أنه في الحالتين لا يمكن للدائن أن ينفذ على المدين إلا بعد تصفية الغرامة التهديدية و تحويلها إلى تعويض .

تصفية الغرامة التهديدية :

تحدد الغرامة التهديدية عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن التنفيذ و بمجرد تحقق الغرض الذي من أجله فرضت يجوز للدائن الرجوع أمام نفس الجهة القضائية المختصة وفقا للقواعد العامة للمطالبة بتحويلها إلى تعويض نهائي مع الأخذ بعين الاعتبار العنت و الإصرار الذي أبداه المدين واحتسابه مع التعويض طبقا لنص المادة 174 و 175 من ق م.

وتتم مراجعة و تصفية الغرامة بموجب حكم بالتعويض ومن ثمة يصبح حكم التعويض نهائيا يمكن الدائن من اتباع اجراءات التنفيذ المقررة قانونا لاستيفاء قيمة التعويض النهائي والوصول حتى اتخاذ إجراءات الحجز وفقا لقانون الإجراءات المدنية .

